



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/42/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

שפיגל נדין	1	תובעות:
כהן אסתר מוריאל,	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד אברהם קורשיה		
נגד		
חברת מזור 6 מגורים בע"מ	1	נתבעים:
באמצעות ב"כ: עו"ד אבנר סאלם		
מלול פתריס (נמחק)	2	
מזור 6, ירושלים		

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם התובעות זכאיות לסעד של הריסת מרפסות שבנתה הנתבעת מעל מרפסות דירות התובעות, לאור זכויות הבניה שנתנו לנתבעת בגג הבית המשותף על פי התקנון המוסכם.

1. כל אחת מהתובעות היא בעלת דירה בבית המשותף שברחוב מזור 6 בירושלים, הידוע כגוש 30073 חלקה 139 (להלן – הבית המשותף). לכל אחת מהדירות הייתה, כך לטענת התובעות, מרפסת לא מקורה אשר יכולה הייתה לשמש כסוכה. דירת התובעת 1 רשומה כתת חלקה 35, ודירת התובעת 2 רשומה כתת חלקה 37.

2. הנתבעת היא בעלת דירה בבית המשותף הרשומה כתת חלקה 8, לה צמוד הגג המשותף הנמצא מעל דירות התובעות, וכן נתנו לה זכויות הבניה על הגג.

3. לבית המשותף תקנון מוסכם אשר נרשם בתאריך 12.3.2013. התקנון קבע תחילה שהגג צמוד לתת חלקה 1, ושכל זכויות הבניה, הקיימות והעתידיות, שייכות לתת חלקה 1 בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מרשויות התכנון והבניה. בנוסף קבע התקנון שבעלי תת חלקה 1 רשאים לבקש לתקן את תקנון הבית המשותף לצורך מימוש זכויותיהם על פי התקנון, בחתימתם בלבד. בהמשך, על פי תיקון תקנון שבוצע ביום 16.11.2021 הועברו ההצמדות וזכויות הבניה על גג הבית המשותף מבעלי תת חלקה 1 לנתבעת, בעלת תת חלקה 8.

טענות התובעות בקצרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/42/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. התובעות רכשו את הדירות כאשר לכל אחת מהן מרפסת לא מקורה, מתוך כוונה לקבל דירה עם אפשרות לבנות במרפסת סוכה בחג הסוכות. לטענתן, הנתבעת נמצאת בבעלות של חברה אחרת, לי – אר (אילון) בע"מ, שמנהלה הוא מר ארצי. מר ארצי היה בעלים של דירה בבית המשותף, תת חלקה 1, לה הוצמדו זכויות הבניה בגג. הנתבע 2, אשר נמחק בהמשך מכתב התביעה, רכש את דירת ארצי ללא הצמדת הגג, אך צו הבית המשותף לא תוקן במועדים הרלוונטיים דבר שגרם להטעיית התובעות ולתביעת הנתבע 2.
5. בשנת 2019 קיבלה הנתבעת היתר בניה לבניית שתי קומות נוספות על גג הבית המשותף. לתובעות נודע על כך רק בחלוף תקופת ההתנגדויות. הנתבעת ידעה שהתובעת 1 מתנגדת לקירוי המרפסת שלה וניהלה איתה משא ומתן על כך. הנתבעת לא פנתה לתובעת 2 טרם התחלת הבניה בטענה שהתובעת 2 חתומה על הסכמה לכך. לטענת התובעת 2, לא הבניה בעת חתימת ההסכם לרכישת הדירה את האמור בהסכם לעניין זכויות הבניה על הגג, וסמכה על קרוב משפחתה שליווה אותה בעסקה ועל עוה"ד שאותו קרוב המליץ לה עליו. לתובעת 2 טענות גם באשר לכך שבהסכם לא הובהר שמדובר בבניה מעבר לקונטור הגג, ובאשר לעדות עוה"ד שייצג את שני הצדדים בעסקה, בטענה שהעדות מהווה הפרה של כללי האתיקה ועל כן יש למחוק אותה.
6. בחודש ספטמבר 2021 התחילה הנתבעת בעבודות הבניה. התובעות פנו זמן קצר לאחר מכן בבקשה לסעד זמני לבית המשפט המחוזי והבקשה נדחתה מטעמי סמכות. ביום 2.2.2022 פנו בבקשה לסעד זמני ובתביעה לערכאה זו.
7. לטענתן, שטח הגג שבבעלות הנתבעת אינו כולל את שטח המרפסות. על פי מסמכי הבית המשותף לתובעות מרפסות לא מקורות. על פי סעיף 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, הבעלות המרפסות הלא מקורות של התובעות מתפשטת בחלל הרום. למרות הסייגים שנתנו לכך בפסיקה לעניין בית משותף, הדבר אינו חל על שטחים פתוחים שהם חלק משטח הדירה.
8. הנתבעת הפרה חובה חקוקה. הבנייה מעל מרפסות דירת התובעות מהווה פגיעה מהותית בזכויותיהן כמשמעותה בסעיף 72 ג לחוק המקרקעין. מצוות סוכה היא חשובה וזכות יסוד ועל כן נקבעה לה הגנה מיוחדת בחוק.
9. התקנון המוסכם מאפשר לנתבעת בניה על הגג בלבד ולא מעבר לו. גם אם מפרשים את התקנון כמתיר בניה מעבר לגג, הנתבעת לא זכאית לבנות מעל מרפסות התובעות לאור הוראות סעיף 71(ב)(ז) לחוק המקרקעין האוסר בניה שמונעת אפשרות לבנות סוכה. הפסיקה בעניין זה פרשה את הסעיף בהרחבה כך שאינה דורשת קיום התנאי שבסיפת הסעיף לעניין השאלה האם בעל הדירה נהג לבנות סוכה. כמו כן אין לפרש את הסעיף כמתייחס לבנית סוכה דווקא במרפסת עצמה, והתובעות העידו שהן נוהגות מתמיד לקיים את מצוות הסוכה.

טענות הנתבעת בקצרה

10. התביעה הוגשה בחוסר תום לב ובשיהוי ניכר, כאשר מרבית העבודות כבר בוצעו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/42/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. על פי ההיתר המקורי של דירת התובעות, המרפסות שלהן היו אמורות להיות מקורות במלואן בחומר קל ולא לשמש כמרפסות סוכה. התובעות מעולם לא הקימו סוכה בבית המשותף. הנתבעות יכולות להוסיף מרפסת סוכה לדירתן על פי היתר קיים והנתבעת הציעה להן לבצע זאת במהלך הבניה והן סרבו.

12. התובעות אינן מתגוררות בדירות, ומעולם לא חגגו בהן את חג הסוכות.

13. תביעה אחרת שהגישה התובעת 1 לבית המשפט המחוזי נדחתה, ונימוקי הדחייה יפים גם לעניין זה. התובעת 2 חתמה על הסכם והייתה מודעת לבניה הצפויה על גג דירתה.

14. יכולת התובעות לבנות מרפסת סוכה אחרת לדירתן על פי ההיתר הקיים מאיינת כל תביעה לירידת ערך בגין הבניה שביצעה הנתבעת.

15. הנתבעת תיקנה את כל הנזקים שנגרמו לדירות התובעות בגין הבניה.

16. על פי תקנון הבית המשותף וההיתרים הנתבעת הייתה זכאית לבנות בחלקים המשותפים.

ההליך

17. ביום 3.2.2022 הגישו התובעות בקשה לסעד זמני. בדיון שהתקיים ביום 16.2.2022 לאחר שנשמעו טענות הצדדים, ביקשו התובעות למחוק את בקשתן ונקבע כי הצדדים יהיו רשאים לטעון להוצאות הבקשה בסיום ההליך.

18. הנתבע 2 נמחק מההליך לאחר שהסתבר שאמנם רכש את הזכויות בתת חלקה 1 אולם זאת ללא הזכויות בגג הבית המשותף וללא זכויות הבניה, אשר הועברו כאמור לנתבעת.

19. ביום 6.6.2022 התקיים דיון מקדמי, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמות לעניין סעדים הנוגעים לתיקון נזקים שנגרמו לדירות התובעות בשל הבניה שבוצעה על ידי הנתבעת.

20. ביום 13.2.2023 התקיימה ישיבת הוכחות. בתחילת ישיבת ההוכחות עלה שהמהנדס שנתן חוות דעת מטעם התובעות לא הוזמן על ידן להיחקר בישיבת ההוכחות, ועל כן הגיעו הצדדים להסכמות לעניין תיקון יתרת הליקויים בדירת התובעת 1, ובהיעדר ראיות אחרות מטעם התובעות לעניין הסעדים הכספיים שנתבעו על ידן, **נותר לדון בסעדים הנוגעים לבניה מעל מרפסות התובעות בלבד.**

21. מטעם התובעות העיד מר ריאחי צ'אלס, קרוב משפחה של התובעת 1, התובעות עצמן, ובעלה של התובעת 2. מטעם הנתבעת העיד עו"ד נווה שייצג את הצדדים ברכישת דירת התובעת 2, מר חיים זקש ששיווק בעבר דירות בבית המשותף, ומר ארצי ששון בעל זכויות עקיף בנתבעת, ובעבר הבעלים של תת חלקה 1, לה היה צמוד הגג וזכויות הבניה עד שאלו הועברו לנתבעת.

22. לאחר מכן הגישו הצדדים סיכומים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/42/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

זכות הנתבעת לבנות מעל מרפסות התובעות

23. סעיף 62 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) כולל הוראות לעניין תקנון בית משותף. ס"ק ג קובע כי "תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן".

24. בתקנון המוסכם של הבית המשותף, אשר נרשם בשנת 2013, נקבע שכל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות שטרם נוצלו תהיינה שייכות לבעלי בעלי יחידה 1/139, והם יהיו רשאים לנצל את זכויות הבניה ולבנות על השטחים הצמודים ליחידה זו ועל כל חלל הרום שמעל שטחים אלו בהתאם לכל תכנית או בקשה להיתר שיאושרו לרבות תוספות בניה וכו', ללא הסכמת יתר בעלי הדירות (סעיף 3 לתקנון המוסכם). ליחידה 1/139 הוצמד בין היתר גג הבית המשותף. בהמשך, הועברו הזכויות בגג המוצמד וזכויות הבניה האמורות ליחידה 1/139, שנרכשה על ידי הנתבעת, ותקנון הבית המשותף תוקן בהתאם לכך בשנת 2021.

25. התובעת 1 רכשה את דירתה, על פי טענתה, בשנת 2014 והתובעת 2 רכשה את דירתה, על פי טענתה, בשנת 2015. משכך, ולאור הוראת סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, תקנון הבית המשותף מחייב את הנתבעות. טענת התובעות שלא ידעו על הוראות התקנון בנוגע לזכויות הבניה על הגג בעת שרכשו את דירותיהן אינן גורעות מזכות הנתבעת לבנות על פי הוראות אלו, והן מחייבות את התובעות בין אם ידעו עליהן ובין אם לא. יתר על כן, בהסכם רכישת הדירה של התובעת 2, צוינו במפורש זכויות הבניה על הגג.

26. הטענה שבניית המרפסות נעשתה על ידי הנתבעת תוך הסגת גבול, משום שנבנתה בשטח השייך לתובעות שכן הוא מצוי בחלל הרום שמעל דירתן, נדחתה. כפי שנקבע בע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807, בעמוד 809, יש לבחון את נושא הבעלות בבית משותף, לרבות את הוראת סעיף 11 לחוק המקרקעין, בשינויים הנובעים מהעניין, כך שהבעלות בדירה מסוימת אינה מתפשטת לדירה שמתחתיה או מעליה. ביישום הלכה זו לעניין בניה מעל מרפסת דירה, קבע בית המשפט המחוזי ע"א (מחוזי תל אביב) 46785-06-20 צירקין נ' היס (נבו 15.11.2022) בפסקה 14 לפסק הדין, שהחלל שמעל מרפסת פתוחה בדירה מתפשט עד לתקרת הקומה של אותה דירה, והחלל שמעליו הוא רכוש משותף. כך שאף אם מרפסת דירת התובעות היא מרפסת פתוחה כטענתן, החלל שנמצא מעל גובה קומת דירתן אינו בבעלותן הפרטית, אלא מהווה רכוש משותף.

27. באשר לטענה שהנתבעת הייתה רשאית לבנות מעל שטח הגג בלבד, אך לא לחרוג מכך, ועל כן לא הייתה רשאית לבנות מעל המרפסות הפתוחות של התובעות, אני מוצאת שדינה דחייה כפי שאנמק להלן.

28. לצורך בחינת טענה זו יש לבחון כיצד יש לפרש את התקנון המוסכם של הבית המשותף.

הוראות התקנון המוסכם הן רחבות מאוד ומתייחסות לזכות הנתבעת לנצל את כל זכויות הבניה על השטחים הצמודים ליחידה שלה, הן הזכויות הקיימות והן העתידיות. הלשון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/42/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרחבה של הוראות התקנון תומכת בפרשנות על פיה הכוונה הייתה לבעל הזכויות בגג הצמוד את האפשרות לבנות כל תוספת בניה בגג ללא הגבלה.

סעיף 3 לתקנון המוסכם כולל הוראות הגוברות הן על הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין, כאמור ברישת הסעיף, לעניין ההסכמה הנדרשת מכל בעלי הדירות לצורך הצמדת חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירת הנתבעת. יתר הוראות הסעיף מקנות לבעלי הזכויות בגג זכויות נרחבות.

כך לדוגמה סעיף 3(א) לתקנון המוסכם קובע כי כל זכויות הבניה שטרם נוצלו בפועל וכן כל זכויות הבניה העתידיות בבית המשותף, תהיינה שייכות וצמודות לבעלים של תת חלקה 8.

סעיף 3(ב) לתקנון המוסכם קובע כי: "בעלי יחידה 139/8 יהיו רשאים לנצל את זכויות הבניה ולבנות על השטחים הצמודים ליחידה על פי שיקול דעתם המוחלט, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך מרשויות התכנון והבניה, והם יהיו רשאים לנצל לשם כך את אחוזי הבניה הקיימים בבית המשותף".

סעיף 3(ג) לתקנון המוסכם קובע: "במימוש זכויותיהם על פי תקנון מוסכם זה, יהיו הבעלים של יחידה 139/8 זכאים לנצל את זכויות הבניה ולבנות, בין בפעם אחת ובין במספר פעמים, בכל השטחים הצמודים ליחידה זו וכן על כן חלל הרום שמעל לשטחים אלה, ככל שהדבר אפשרי...לרבות "שינוי יעוד" ו/או הקלות מכל מין וסוג, וכל תוספות הבניה שייבנו על ידם מכוח זכויותיהם על פי תקנון מוסכם זה, לרבות גגות חדשים שיווצרו כתוצאה מהבניה שתבוצע על ידם, יהיו אף הן שייכות וצמודות להם בלבד...".

29. בע"א 2427/11 **מפעל חסד תורה ירושלים ת"ו נ' ננסי פליישמן** (נבו 11.3.2014) נמצא שגם כאשר הוקנו זכויות בניה על הגג **מבלי להוציא את הגג מגדר הרכוש המשותף** והצמדתו לדירה פלונית, קיימת זכות למי שהוקנו לו זכויות הבניה לבנות על הגג, תוך שהגג החדש יהיה רכוש משותף. בכלל זה נקבע בעמודים 18-19 לפסק הדין:

"מתוך תניות והסכמות אלה שנכללו בהסכמים ובמפרטים עולה, אם כן, כי בין המשיבים לעמותה נקשרה הסכמה חוזית לפיה תוכל העמותה לבנות על גג הבניין – אף שהוא לא הוצא מגדר הרכוש המשותף – וכי היחידות החדשות אשר תיבנינה על ידי העמותה, שייכות לה ותירשמנה על שמה (ראו ענין קל"ן, בפס' 6 לפסק דיני; ענין קאופמן, בפס' 14)..."

המסקנה העולה מן האמור לעיל היא, אפוא, כי גגות הבניינים הם אמנם בגדר רכוש משותף. יחד עם זאת המשיבים ויתרו על זכויות הבניה במקרקעין בכלל ובגגות הבניינים בפרט, והסכימו להקנותן לעמותה תוך הגבלת הבניה בהם לארבע קומות מעל פני הקרקע. אוסיף ואציין כי נוכח המסקנה האמורה, מתבקשת לגישתי מסקנה נוספת והיא – כי הגגות החדשים שיווצרו לאחר תוספת הקומות כאמור, יבואו חלף הגגות הקיימים ויהיו אף הם רכוש משותף. "



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/42/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. ראו והשוו גם ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון** (נבו 27.8.2009) שם נמצא שיש מקום לאפשר בניה על הגג לאור הסכמים למתן זכויות הבנייה בבית המשותף, אף שנקבע שהמצב המשפטי אינו מאפשר הצמדת הגג לבעל זכויות הבנייה, וכי הוא מהווה רכוש משותף.

31. מהאמור עולה שהפרשנות שנתנה להוראה חוזית, וקל וחומר להוראת תקנון, המקנה את כל זכויות הבנייה היא, שבעל זכויות הבניה זכאי לבנות גם **ברכוש המשותף** ולא רק על החלק שהוצמד ליחידה שבבעלותו. ודאי כך בענייננו, כאשר אין מחלוקת שהגג הוצמד ליחידת הנתבעת על פי הוראות התקנון, ו**בנוסף על כך** הוקנו לה כל זכויות הבנייה, הן הקיימות והן העתידיות, שהיא רשאית לבנות לא רק על אותו חלק שהוצמד על פי התקנון, אלא גם על חלקי הרכוש המשותף שהם נתנו לה זכויות בנייה. דבר המקבל חיזוק נוסף כאשר מדובר בבניה שהיא חלק בלתי נפרד מתוספת הבניה על גבי הגג.

32. בנוסף, בענייננו, אמנם אין המדובר בהרחבת דירה אלא בזכויות לבצע בניה נוספת על הגג, אולם הפסיקה העוסקת בהרחבת דירה, הבהירה כי תוספת בניה אין משמעותה בניה לגובה בלבד, והיא יכולה להתפרס גם לרוחב.

סימן ג1 לחוק המקרקעין מאפשר להתגבר על הוראת סעיף 62 לחוק המקרקעין לעניין הסכמת כל בעלי הדירות לצורך הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, וזאת לצורך ביצוע הרחבה של דירה, כל עוד אין בתקנון המוסכם של הבית המשותף הוראות אחרות.

הרחבת דירה כאמור, פורשה בפסיקה כהמשך טבעי של הדירה, בין אם אנכית ובין אם אופקית, כפי שנאמר בע"א (מחוזי ירושלים) 3418-09 **עטיה נ' שגיא** (נבו 17.1.2010):

"הרחבה זו יכולה להיות בדרך אנכית - כגון פריצת תקרת הדירה אל עבר גג הבניין, או פריצת רצפת הדירה אל עבר קומה שמתחתיה. או הרחבה אופקית - כגון בניית מרפסת או סגירתה או פריצת קיר הדירה אל עבר הרכוש המשותף הצמוד לה"

בניית מרפסת, אף **מרפסת תלויה**, רואים בה כהרחבת דירה [ר' לדוגמה עש"א (מחוזי חיפה) 34884-04-15 **מלכה נ' פרידלנדר** (נבו 18.10.2015) (להלן – **ענין מלכה**); עש"א (מחוזי חיפה) 50945-05-12 **ברק נ' קרש** (נבו 19.5.2013), בפסקה 12]. יתר על כן, **בעניין מלכה** נמצא שההוראות התקנון המוסכם, שאסרו באופן מפורש שינויים חיצוניים בבית המשותף, אינן גוברות על הוראת סימן ג1 לחוק המקרקעין, אשר חוקק לפני רישום התקנון, וכי רק הוראה מפורשת בתקנון האוסרת הרחבת דירה, יכולה הייתה להתגבר על הזכות להרחיב דירה באמצעות בניית מרפסת ברוב האמור.

סימן ג1 האמור אמנם אינו חל בענייננו, אבל יש בפרשנות הפסיקה לעניין האופנים בהם ניתן להרחיב דירה, אף כאשר לא קיימות הוראות בתקנון המוסכם המאפשרות זאת, ואף באופן החורג מקונטור הבית המשותף כאשר יש בתקנון הוראות מפורשות בנוגע למראהו, כדי להשליך על פרשנות התקנון המוסכם בענייננו, המקנה את הזכות להשתמש בזכויות הבניה באופן מפורש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/42/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. הפרשנות האמורה של התקנון, נתמכת גם באופיו של הבית המשותף. על פי תשריט הבית המשותף, קונטור הבית המשותף הוא אחיד לכל אורכו וכולל מרפסות מקורות הנמצאות מתחת למרפסות דירות התובעות, כאשר המרפסות שבקומת דירות התובעות מסומנות כמרפסות לא מקורות. פרשנות על פיה למרות לשונו הרחבה של הסעיף, נמנעת מבעלי הזכויות בגג לבנות אופקית המשך לדירות הנבנות על הגג, באופן המשתלב עם קונטור הבית המשותף הכולל מרפסות לכל אורכו, אינה מתיישבת עם הזכויות הנרחבות שנתנו לבעלי זכויות כאמור. פרשנות סבירה להוראות התקנון מניחה שאם ייבנו קומות נוספות לבית המשותף, כפי שהתקנון מאפשר, ניתן יהיה לבנות אותן בקונטור הבית המשותף. לאור אופי הבית המשותף שכל המרפסות בו בקומות שמתחת לקומת דירת התובעות הן מרפסות מקורות, הרי שאם הייתה כוונה לתת זכות מיוחדת לבעלי הדירות בקומה העליונה שלא יבנו מעל מרפסות דירותיהם, למרות הזכויות הנרחבות שנתנו לבנייה על הגג ללא הסכמת יתר בעלי הדירות, הרי שהיה מקום לציין זאת במפורש בתקנון. גם העובדה שמרפסות דירות התובעות מופיעות כמרפסות שאינן מקורות בתשריט הבית המשותף, אין בה כדי להקנות זכות לתובעות שלא יבנו מעליהן בהמשך, מה גם שסעיף 3(ז) לתקנון המוסכם מקנה זכות לנתבעת להגיש בקשה לתיקון צו הבית המשותף באופן שיביא לידי ביטוי את תוספות הבניה שבוצעו על ידה בהתאם לתקנון. כפי שתשריט הבית המשותף אינו שולל תוספת קומות שאינן מופיעות בו כיום, כך אינו שולל בניה מעל מרפסות קיימות.

34. אוסיף על האמור, שגם התנהלות הנתבעת לאחר רישום התקנון, ועוד לפני שהתובעות רכשו את דירותיהן, תומכת בפרשנות האמורה.

מעדות ארצי ששון, מי שהיה פעיל בקבוצת הרכישה שרכשה את הבית המשותף, ובעל זכויות בעבר בתת חלקה 1 לה הוצמדו הגג וזכויות הבניה, וכן בעל מניות בחברה שהיא הבעלים של החברה הנתבעת, עלה שעל פי היתרי הבניה של הבניין, עוד טרם רכישת הדירות על ידי התובעות, מרפסות דירות התובעות אמורות היו להיות מקורות בקירוי של פח אבץ (סעיפים 4-5 לתצהירו ונספחים 1-2). דבריו של ששון חוזקו בכך שמבנה מרפסות דירות התובעות אינו מבנה סטנדרטי של מרפסת פתוחה, שכן קיימות בהן תשתיות של קורות בטון להצבת גג מעליהן (פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2023 עמוד 13 שורות 45-49).

עדות זקש, מי שהיה מעורב בעבר בשיווק הדירות בבית המשותף לאחר שנבנה, אף היא חיזקה את הדברים, שכן הוא העיד שהיה קושי להשכיר את הדירות בשל העובדה שלקוחותיו חרדים וכל הדירות בבית המשותף היו ללא מרפסות סוכה, דבר שהובחר לו במפורש בזמנו על ידי ארצי אף לגבי דירות בקומה העליונה, כאשר על פי עדותו באותה עת המרפסות בקומה העליונה היו מקורות (ר' דבריו בחקירה ראשית בעמוד 12 שורות 16-28). דבריו לא נסתרו בחקירתו הנגדית.

35. למעלה מן הצורך אוסיף שבמכלול הנסיבות עולה שככל שאכן נושא מרפסות הסוכה היה כל כך משמעותי עבור התובעות, הרי שהיה מצופה שיערכו בירור בעניינו טרם רכישת הדירות, אולם מעדויותיהן עולה שבירור כאמור לא נעשה. עניין זה פועל אף הוא לחובת התובעות, אשר לא הוכיחו שהן עצמן נתנו לתקנון פרשנות שונה בעת שרכשו את דירותיהן.

באשר לתובעת 2, זכות הנתבעת לבנות קומות נוספות על הגג הובהרה במפורש בהסכם שנחתם עמה, אם כי לטענתה לא כל כך ידעה עברית ולא הבינה את ההסכם וסמכה על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/42/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עורך הדין שלה, ובכל מקרה לא הבינה שהכוונה גם לבניית מרפסת מעל המרפסת שלה (עמוד 8 שורות 48-37, עמוד 9 שורות 7-1). עו"ד נווה, אשר ייצג את שני הצדדים בעסקת רכישת הדירה, העיד בחקירתו הראשית שהתקשורת בינו לבין התובעת 2 בעת הרכישה הייתה מצוינת ובעברית, וכי הבהיר לה במפורש את עניין זכות הנתבעת לבנות על הגג ווידא שהיא מבינה את הדברים, ואף הקריא לה את כל החוזה טרם החתימה והסביר לה את המשמעויות (עמוד 10 שורות 13-1). עדותו לא נסתרה, ובחקירתו הנגדית הוסיף לעניין הבניה מעל המרפסת, שהבהיר לתובעת 2 שהמוכר יכול לבנות מעליה איך שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, ולא מצא צורך לדבר ספציפית על המרפסת (עמוד 11 שורות 39-35). מהתרשמותי מעדות עו"ד נווה, אני סבורה שהציג את הדברים באופן נאמן למציאות, בעוד שעל פי התרשמותי, התובעת 2 הציגה את הדברים באופן מוטעם, כאילו לא הבינה במעמד חתימת ההסכם שיבנו מעליה, והגזימה באשר לחוסר הבנת העברית (אציין כי התובעת 2 מתגוררת בישראל כבר 20 שנים על פי עדותה – עמ' 7 שורות 47-46). דווקא האופן בו הציגה התובעת 2 את החשיבות שראתה בקיומה של מרפסת סוכה בדירה, מעלה תהיות על כך שלא עשתה בירור מקיף בעת רכישת הדירה אודות ההתכנות לבניה מעל המרפסת כאשר נמסר לה במפורש שקיימות זכויות לבניית 2 קומות נוספות מעל דירתה, וכן מעלה תהיות באשר לכך שכלל לא הגיעה לראות את הדירה לפני שרכשה אותה, אלא סמכה על האחיין שלה ועל כך שיש לה 2 אחיות שיש להן דירות בבניין (ללא מרפסת סוכה). כן טענה שהאחיין שלה הראה לה סרט של הדירה, אולם סרט כאמור לא צורף לראיותיה בטענה שלא יכלה למצוא אותו (עמוד 7 שורות 34-23). בעלה של התובעת 2 העיד שלא ראה את הדירה לפני שנקנתה, שידע כבר אז על הכוונה לבנות קומות נוספות, ושעמד מחוץ לבניין והסתכל למעלה, תוך שטען שראה שהמרפסת פתוחה מלמטה (עמוד 6 שורות 25-32). למותר לציין שבהסכם הרכישה של התובעת 2 לא הוזכרה מרפסת סוכה. במכלול הנסיבות עולה כי אין בסיס לטענת התובעת 2 שקיומה של מרפסת כאמור היוותה היבט משמעותי מבחינתה ברכישת הדירה.

באשר לתובעת 1, עלה מעדותה שלמרות הוראות התקנון המוסכם, שהיו קיימות כבר שעת שרכשה את הדירה, כלל לא ידעה על זכויות הבניה הקיימות על הגג מעל דירתה בעת רכישת הדירה (עמוד 4 שורות 8-1). מכאן שממילא לא ערכה כל בירור באשר להיקף הזכויות האמורות, ולא עשתה כל בירור באשר לאפשרות שתבוצע בעתיד בנייה מעל מרפסת דירתה, למרות שחשיבות שנתנה לטענתה לכך שיש בדירה מרפסת פתוחה.

מכל מקום, כאמור, התקנון המוסכם של הבית המשותף מחייב את התובעות בין אם היו מודעות לאמור בו בעת רכישת הדירה ובין אם לא.

היעדר תחולה להוראת סעיפים 71ב(ז) ו-71ג(ד) לחוק המקרקעין

36. סעיף 71ב(ז) **שבסימן 11 לחוק המקרקעין** קובע, כחריג לזכות רוב בעלי הזכויות במקרקעין להחליט על הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה מסוימת לצורך הרחבתה, כי **"לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה"**. התובעות טוענות שהבניה בוצעה בניגוד לסעיף זה, ובכל מקרה פוגעת בדירתן על פי סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/42/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. **סימן ג1 לחוק המקרקעין**, הכולל את הסעיפים האמורים **כלל אינו חל בענייננו**. סימן ג1 האמור, נועד למקרה של הרחבת דירה בלבד, תוך שהוא מאפשר לרוב מסוים של בעלי דירות בבית המשותף להחליט על ביצוע הרחבה תוך ביצוע הצמדה של חלקים מהרכוש המשותף ומתן זכויות הבניה הנדרשות לכך, למרות האמור בסעיף 62 לחוק המקרקעין, הדורש החלטה של כל בעלי הדירות לצורך כך. הרציונל של הסעיף הוא מחד להקל על האפשרות להרחיב דירה, כאשר הוראות התקנון אינן קובעות הוראות בעניין, ומאידך, לשמור על זכויותיו הקנייניות של בעל דירה שזכויותיו הקנייניות עלולות להיפגע כתוצאה מהרחבה כאמור. בענייננו, זכויות הבניה של הנתבעת המאפשרות לה לבנות על גג הבית המשותף, לרבות מעל מרפסות התובעות, קיימות מלכתחילה, על פי הוראות התקנון, ועל כן לא קיימות לתובעות זכויות שיש להגן עליהן בהקשר זה.

38. יתר על כן, גם במקרה של הרחבת דירה, אין מניעה שהוראות התקנון המוסכם יגברו על הוראות סימן ג1 לחוק המקרקעין, בהתאם לאמור בסעיף 71ד לחוק המקרקעין, ובכלל זאת יגברו גם על הוראת סעיף 71ב(ז) וסעיף 71ג(ד).

39. למעלה מן הצורך, אוסיף שהתובעות לא הוכיחו את התקיימותם של התנאים שבסעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין.

הסעיף קובע שני תנאים שהתקיימותם שוללת קבלת החלטת הרחבה. האחד, שיש בהחלטה כדי למנוע אפשרות לבנות סוכה, והשני, שנהג "לעשות כן" לפני ההחלטה.

בעת"מ (מחוזי תל אביב) 34648-07-19 **ברנד נ' ועדה מחוזית** (נבו 26.3.2020) בו נתקפה החלטת ועדה מחוזית שדחתה התנגדות לתכנית מרפסות המביאה לבניה מעל מרפסת סוכה של העותרים, נאמר בהקשר הקנייני:

"בכלל כך, כפי שכבר פורט לעיל, על מנת לקבוע כי קיימת אמנם פגיעה יש לבחון - האם אמנם קיימת לבעל הדירה זכות לפי **סעיף 71ב(ז)** קרי האם נהג לבנות סוכה בעבר בדירתו? ; האם הבניה שוללת זכותו זו? ; האם לצורך קיום הדרישה נשוא הסעיף די בכך בעל דירה יוכל לבנות סוכה כדין או שמא קיימת לו הזכות לבנות סוכה במידות כפי שבנה קודם לכן? ; וכיוצא באלו - שאלות אשר תשובות להן משליכות על השאלה האם אמנם קיימת פגיעה אם לא ואשר מלמדות על כך שהפגיעה נשוא הדיון בענייננו אינה מובהקת ובהתאמה לכך שהגשת התכנית כאשר היא נתמכת בהסכמת רוב בעלי הדירות נשוא התקנות, גם בלא הסכמת העותרים – היא על פניו תוך שקיים לה תימוכין קנייני. "

בענייננו, אף שדירות התובעות נרכשו מספר שנים לפני שבוצעה הבניה, הרי שהתובעות לא התגוררו בהן, וממילא לא נהגו לבנות בהן סוכות, ואף לא נטען ולא הוכח שמי שכן התגורר בדירות בנה סוכות כאמור. איני סבורה שעצם היות התובעות שומרות מצוות, הנהוגות לבנות סוכות בחג הסוכות, די בו כדי לענות על דרישת הסעיף.

התובעות לא טענו שנהגו לבנות סוכה במרפסות האמורות, אלא טענו באופן כללי למנהג לקיים את מצוות חג הסוכות. התובעת 1 כאמור כלל לא הייתה בישראל בחג הסוכות מאז רכשה את הדירה (פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2023 עמוד 4 שורות 13-17), ואילו התובעת 2 מתגוררת באופן קבע בנתניה, ומעולם לא התגוררה בדירה, אולם טענה שיש לה תכניות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/42/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לגור בה בעתיד (ר') פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2023 עמוד 7 שורות 50-46 עמוד 8 שורות 1-4).

באשר לאפשרות שיש בהחלטה כדי למנוע בניית סוכה, הרי שהנתבעת הוכיחה שלצרכי פשרה הסכימה לבנות לתובעות על חשבונה מרפסות סוכה חלף המרפסות הקיימות.

ששון העיד כי על פי היתר בניה קיים, ניתן להוסיף כיום מרפסות סוכה לדירות התובעות (סעיפים 13, 20 לתצהירו). התובעות לא סתרו טענה זו. אין מחלוקת בין הצדדים שניתן להוסיף לדירת התובעת 1 מרפסת סוכה חלף המרפסת האמורה, ואף שהנתבעת הציעה בשלבים מסוימים, לצורך פשרה, לבנות מרפסת כאמור ללא עלות עבור התובעת. התובעת 1 סרבה לכך משום שהמרפסת האפשרית הייתה נבנית לטענתה קרוב מאד לדירת שכנתה, שהיא "משוגעת שצורחת כל היום" (ר') לדוגמה חקירתה הנגדית של התובעת 1 בעמוד 4 שורות 25-30). התובעת 2 אף היא הודתה שהנתבעת הציעה לבנות עבורה מרפסת כאמור אולם טענה שנדרשה לשלם על כך ושכיום כבר לא ניתן לבנות מרפסת כזו (עמוד 8 שורות 32-7). הטענה שלא ניתן כיום לבנות מרפסת סוכה כאמור לדירת התובעת 2 נטענה על ידה באופן כללי בחקירתה הנגדית, ולא מובן על מה היא נסמכת, כאשר כבר בכתב ההגנה נטען כי ההיתר הנוכחי מאפשר בניית מרפסות כאמור (סעיף 14 לכתב ההגנה). בנסיבות אלו, אני מקבלת את טענת הנתבעת, על פיה הייתה קיימת אפשרות לתובעות לבנות מרפסת סוכה לדירתן חלף המרפסות הקיימות.

40. אני ערה לאמור בעש"א (מחוזי ירושלים) 48941-10-18 **דיין נ' אילון** (נבו 24.9.2019) שהוזכר על ידי התובעות בנוגע לאפשרות שאף אם לא מתקיימים תנאי סעיף 71ב(ז) לחוק המקרקעין, יכול שמתקיימים באותו הקשר תנאי סעיף 71ג(ד) לחוק המקרקעין, לעניין פגיעה מהותית בזכותו של בעל דירה. ראשית, כאמור, סעיף זה כלל אינו חל בענייננו שכן לא מדובר בהרחבת דירה על פי החלטת רוב בעלי דירות, אלא בזכות לבנות בניה נוספת על פי הוראות התקנון. שנית, לא הוכחה פגיעה מהותית כאמור, שכן לא די בעצם הטענה לפגיעה ביכולת לבנות סוכה כדי להביא למסקנה שמדובר בפגיעה מהותית.

שיהוי בהגשת התביעה

41. מתצהיר התובעת 1 עולה שלכל הפחות בשנת 2019 נמסר לה על כך שהנתבעת מתכננת לבנות 2 קומות נוספות מעל הדירה שלה. למרות זאת התובעת 1 המתינה כ-3 שנים, והגישה את התביעה רק לאחר שהבניה בוצעה בפועל (ר') חקירתה הנגדית של התובעת 1 בעמוד 5 שורות 13-45). כן עולה שהתובעת 1 הגישה בקשה לסעד זמני באותו עניין לבית המשפט המחוזי בהליך ת"א 59754-10-21. בהחלטה שנתנה ביום 25.10.2021 נדחתה הבקשה, תוך שצוין בין היתר בהחלטה שהתובעת 1 לא פירטה מתי נודע לה לראשונה על היתר הבניה שיחסום את המרפסת, דבר שאירע לכל המאוחר במאי 2019, עת נשלח מכתב מטעם בא כוחה ולא הסבירה מדוע מאש אותו מועד לא פעלה לביטול ההיתר או בכל הליך אחר אשר ימנע את הבניה. בהחלטה הוער גם בנוגע לשקילת הערכאה הרלוונטית אליה יש להגיש את התביעה. בעקבות כך, רק בתאריך 3.2.2022, יותר מ-3 חודשים לאחר מתן ההחלטה, וכאשר מרפסות הנתבעת כבר היו בניות, הוגשה הבקשה לסעד זמני במסגרת הליך זה, ואף בה לא הובהר מדוע התובעת 1 לא פעלה בעניין ההיתר שכלל את סגירת מרפסת דירתה אף שידעה על כך לכל המאוחר במאי 2019.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/42/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

42. התובעת 2 מצדה לא הבהירה מתי נודע לה על כוונת הנתבעת לבנות מעל מרפסת דירתה, אולם היא כאמור ידעה באופן פוזיטיבי על הכוונה לבנות על גג הבית המשותף, אשר באה לידי ביטוי בהסכם שחתמה עליו, ולמרות זאת לא פעלה לבירור היקף הבניה הצפוי ולמניעת הבניה שנעשתה לטענתה שלא כדין, טרם ביצועה.

43. העובדה שהתובעות המתינו עם הגשת התביעה עד לאחר ביצוע הבניה בפועל, אף שכוונת הנתבעת, או לכל הפחות אינדיקציות משמעותיות לכוונה זו היו ידועות להן זמן רב קודם לכן, מחזקת אף היא את השיקולים שלא לתת את הסעד במבוקש.

טענות נוספות

44. כאמור, הסעד היחיד שנותר לדון בו בשל הסכמות הצדדים במהלך ההליך, הוא בקשת התובעות להרוס את המרפסות שבנתה התובעת. למרות זאת בסיכומיהם ביקשו התובעות באופן כללי, לחייב את הנתבעת בפיצויים (סעיף 43 לסיכומים). התובעות לא פירטו בגין מה מבוקשים הפיצויים הנטענים, ובכל מקרה לא הוכיחו במסגרת ההליך שנגרמו להם נזקים, הנמצאים בסמכות ערכאה זו, המזכים אותן בפיצויים, ומהו סכום הפיצויים הנטען על ידן. בהקשר זה אציין שהמהנדס שנתן חוות דעת אודות הליקויים בדירת התובעות לא הגיעו לשיבת הוכחות כדי להיחקר על תצהירו, והצדדים הגיעו להסכמה במהלך הישיבה באשר לסעדים הנוגעים לליקויים הנטענים בדירת התובעות, וההסכמות קיבלו תוקף של החלטה (פרוטוקול הדיון מיום 13.2.2023 עמוד 1 שורות 1-22, עמוד 2 שורות 1-12). בנסיבות אלו גם טענות התובעות לעניין זכאותן לפיצויים מהנתבעת נדחות.

סיום

45. מכל האמור עולה כי סעדי התביעה בכל הנוגע לפירוק המרפסות שנבנו ולפיצוי כספי נדחים. כמו כן עולה כי הסעדים הנוגעים לליקויים שנגרמו לדירות התובעות בשל עבודות שבוצעו מטעם הנתבעת התייתרו בשל הסכמות הצדדים לעניין תיקון הליקויים על ידי הנתבעת.

46. בנסיבות אלו יש מקום להתחשב לעניין הוצאות ההליך, בהצדקה שהייתה להגשת התביעה בסעדים הנוגעים לתיקון הליקויים בדירת התובעות, ובסעדים שנדחו ואשר בעניינם לא היה מנוס מקיום ישיבת הוכחות. יש להתחשב גם באופן בו הוגשה הבקשה לסעד זמני, אשר נקבע בעניינה כי הצדדים יהיו רשאים לטעון בעניין הוצאותיה עם סיום ההליך. לפיכך אני קובעת שעל התובעות יחד לשלם לנתבעת הוצאותיה בסך של 18,000 ₪.

ניתן היום, י"ז חשוון תשפ"ד, 01 נובמבר 2023, בהיעדר הצדדים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/42/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים**